

1500004-38.2022.8.26.0633

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RAFAEL VIEIRA PATARA

Comarca: Itanhaém

Foro: Foro de Itanhaém

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Repto(a)(s):

LUCIANA DE JESUS JACOB e ROBSON VIEIRA MICHELINI

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

ROBSON VIEIRA MICHELINI e LUCIANA DE JESUS JACOB, já qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itanhaém

3ª Vara

Avenida Rui Barbosa, 867, ., Centro - CEP 11740-000, Fone: (13) 3422-1215,

Itanhaém-SP - E-mail: itanhaem3@tjsp.jus.br

Processo nº:

1500004-38.2022.8.26.0633

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Repte(a)(s):

Justiça Pública

Repto(a)(s):

LUCIANA DE JESUS JACOB e ROBSON VIEIRA MICHELINI

MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). RAFAEL VIEIRA PATARA.

Vistos.

ROBSON VIEIRA MICHELINI e LUCIANA DE JESUS JACOB, já qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal porque no dia 1º de janeiro de 2022, por volta das 02h35min, na Av. Flacidez Ferreira, Gaivota, nesta cidade e comarca de Itanhaém, os agentes supra apontados, agindo previamente ajustados e com identidade de propósitos, traziam consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 08 (oito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida por maconha, com peso bruto de 24 gramas e 39 (trinta e nove) porções de cocaína, com peso bruto de 56 gramas, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 18.08.2022 (pág. 196).

Os réus foram citados (págs. 208 e 224) e apresentaram resposta escrita à acusação (págs. 211/213 e 231/233).

Durante a instrução, foram inquiridas duas testemunhas comuns e ao final foi

realizado o interrogatório dos réus (págs. 316/318).

O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado aos autos à pág. 206.

Em fase de memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da presente procedência da pretensão punitiva, condenando-os nos exatos termos da denúncia.

A defesa de Robson Vieira Michelin, por sua vez, requereu a improcedência da ação, com fulcro no artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, absolvendo-se o acusado ou, requer-se a desclassificação do crime para o artigo 28 da Lei 11.343/06 e, caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada a redução prevista no §4º do artigo 33 da Lei de drogas, bem como a redução prevista no artigo 41 da mesma lei. Por fim, que tenha o direito de recorrer em liberdade.

A defesa de Luciana de Jesus Jacob, requereu a absolvição, de acordo com o artigo 386, inciso V e VII, do CPP e, caso não seja esse o entendimento, que a pena seja aplicada no mínimo legal e a pena reduzida nos termos do artigo 33, §4 da Lei 11.343/06 e o cumprimento do regime inicial em aberto.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 03), pelo boletim de ocorrência (págs. 09/11), pelo auto de exibição e apreensão (pág. 12), pelo laudo de exame químico toxicológico (pág. 206), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução.

A autoria também é inconteste e deve ser atribuída aos acusados.

A testemunha arrolada pela acusação, Victor Hugo Ferreira Lima, ouvido em Juízo, Policial Militar, disse que na data dos fatos estavam em patrulha pelo local quando perceberam uma movimentação estranha em uma sorveteria e, em dado momento, Robson e Luciana começaram a discutir e entraram em vias de fatos, razão pela qual, os abordaram. Em revista pessoal, com Robson, em sua bermuda, fora encontrada uma sacola plástica preta, tendo ele confessado que teria entorpecentes na sacola e que estaria na traficância. Por fim, disse que com a ré nada fora encontrado.

A testemunha arrolada pela acusação, Ana Caroline Berthe Souza Silva, ouvida em Juízo, Policial Militar, apresentou os mesmos fatos que seu colega de farda, aduzindo que quando o réu fora indagado, confessou que estava vendendo e que sua esposa, ora ré, buscava os entorpecentes para ele vender. Informou que ao indagar a acusada, ela relatou que os entorpecentes que estavam sob a posse do réu, na verdade, lhe pertenciam.

Não há razão suficiente para invalidar os depoimentos dos Policiais, por suspeitos ou impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade, pois, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que:

"(...) nada impede que policiais ou outros servidores públicos, como quaisquer pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos destes como se, em princípio, não fossem dignos de credibilidade. Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse os depoimentos de seus próprios servidores. A propósito do valor probante de testemunhos policiais, oportuno trazer

à colação a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: 'VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência.' (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293)" (TJSP, Apelação nº 0009710-21.2011.8.26.0176, 14ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. HERMANN HERSCHANDER, j. 31.03.2016).

Os testemunhos dos Policiais são suficientes para, com as demais provas carreadas aos autos, comprovar a ocorrência do fato típico, e embasar um decreto condenatório aos réus, vez que dotado de fé pública e idoneidade em sua alegação, mormente por ter corroborado o depoimento na fase inquisitorial.

O réu, Robson Vieira Michelini, interrogado em Juízo, confessou os fatos descrito na denúncia. Disse que morava com a ré há aproximadamente um ano e, em momentos de dificuldade financeira, ela buscava os entorpecentes para que ele pudesse vender. Contudo, no momento da abordagem, não estava realizando a prática de venda.

A ré, Luciana De Jesus Jacob, interrogada em Juízo, negou os fatos descritos na denúncia. Disse que na data dos fatos passaram a discutir por causa de ciúme. Negou ter ido buscar entorpecentes, assim como negou ser usuária. Esclareceu que no momento da abordagem informou aos policiais que a droga era sua, pois fora ameaçada pelo réu, contudo, tinha conhecimento de que ele estava traficando, pois estavam passando por dificuldades financeiras.

Pois bem.

Embora a ré haja negado a autoria, sua versão restou isolada perante a confissão do réu e os depoimentos dos policiais. Portanto, a responsabilidade penal dos réus é nítida, mormente pelas provas colhidas, em especial pela prisão em flagrante e o auto de exibição e apreensão, tornando-se prova idônea da prática delitiva.

Necessário destacar, ainda, que o tráfico de drogas é praticado às ocultas, logo, para se prolatar decisão condenatória não há necessidade de uma sequência de provas plenas e fartas, pois tal situação não se coaduna com a realidade fática.

A decisão condenatória deve se basear em um quadro suficiente de elementos de convicção, que seja harmônico e convergente para configurar a conduta dos réus, o que de fato ocorre no presente caso.

Ainda que assim não fosse, é sabido que todos os processos criminais exibem, em maior ou menor escala, algum coeficiente de incerteza, cumprindo ressaltar, porém, que é despropositado exigir, para a procedência da acusação, grau absoluto de certeza, de vez que a solução condenatória reclama, tão só, prova suficiente da autoria e da materialidade, que não se identifica com prova maciça, incontestável, reflexo sem distorções da realidade. E prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível, ou seja, juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão.

Nem se diga que a existência apenas de indícios impossibilite um decreto condenatório, pois contrariaria doutrina e jurisprudência majoritárias:

"embora não leve à certeza, a jurisprudência tem admitido a condenação quando a prova indiciária for veemente ou então quando várias pequenas circunstâncias sejam, concordes até em detalhes. Um único indício pode levar à condenação, desde que veemente. Por indício veemente entende-se aquele que, dada a sua natureza, permite razoavelmente afastar todas as hipóteses favoráveis ao acusado. (...) Às vezes uma sucessão de pequenos indícios, coerentes e concatenados, igualmente podem dar a certeza exigida para a condenação. (...) Em tal hipótese não encontramos um indício que possa ser classificado como veemente, porém a sucessão e a coerência indicam a autoria com uma dose de razoabilidade bem marcante" (Da Prova no Processo Penal - José Q. T. de Camargo Aranha).

"A prova se faz não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções, que devem ser analisados como todo e qualquer outro elemento de convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os indícios, quando não contrariados por contra indícios, ou por prova direta, autorizam o juízo e culpa do acusado e sua condenação." (TACRIM-SP - AC - Rel. Marrey Neto - JTACRIM 7/105).

Como se vê, ficou clara a prática de tráfico ilícito de entorpecentes por parte dos réus, inexistindo nos autos qualquer fato que venha ilidir sua responsabilidade penal.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade e diversidade, denotam, às claras, sua predisposição: a entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

"TÓXICOS - Tráfico - Agentes presos em flagrante quando transportavam 561 gramas de maconha - Ausência de prova direta da finalidade mercantil - Irrelevância à caracterização do delito. Não é apenas a quantidade de substância entorpecente que deve influir no julgamento, mas o conjunto de fatores expressamente previstos no artigo 37 da Lei nº 6.368/76. Até porque, segundo ponderável corrente jurisprudencial, para a configuração do delito de tráfico, na forma consumada, não é indispensável que o agente efetue a comercialização da droga. Basta que a possua, guarde ou a tenha em depósito, sobretudo em grande quantidade, circunstância denunciadora da mercancia. - Recurso conhecido e provido." (TJMG, ACr nº 263.616-5/00, 1ª Câmara Criminal, Relª Desª MÁRCIA MILANEZ, j. 07.05.2002).

Para ilustrar, aponto as lições de LUIZ FLÁVIO GOMES:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Devem-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. Al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197).

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Nesta toada, o conjunto probatório delineado nos autos é mais do que suficiente para empregar o decreto condenatório em desfavor dos réus.

Passo a dosar a pena.

RÉU ROBSON VIEIRAMICHELINI

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 37/38) observo que o réu não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...] (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).
Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d" do Código Penal, entretanto, a pena não poderá ficar aquém do mínimo legal por força da súmula nº 231 do STJ, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, vislumbro estar presente a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e a acusação não conseguiu comprovar que o réu se dedicava a atividade criminosa, nem que integrasse qualquer organização, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa.

Sobre a redução acima aplicada, destaco que nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4.º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo" (HC 103225 - RN, 2.ª T., rel. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u.).

Segundo o renomado jurista e magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 §4º, da Lei 11343/06:

"cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Não existem dúvidas quanto aos requisitos da "primariedade", "bons antecedentes" e "integrar organização criminosa", mas estranha é a previsão a respeito de "não se dedicar às atividades criminosas". Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita" (grifo nosso).

No caso em tela o réu é primário, impossibilitando, desta forma, a presunção de que se dedique a atividades criminosas. Pelo contrário, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a comprovação dos requisitos "dedicação às atividades criminosas" e "participação em organização criminosa" é ônus da acusação.

Desta forma, sendo o réu primário, e não logrando a acusação comprovar que efetivamente integrasse em organização criminosa, tão pouco se dedicasse a prática de crimes, impossível a não concessão do redutor no caso em tela.

Portanto, será concedido no mínimo legal, pois a quantidade apreendida não pode ser considerada pequena, mas também nada que leve à presunção de que o réu integrava organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

RÉ LUCIANA DE JESUS JACOB

Na primeira fase da dosimetria da pena, observando as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, e analisando a folha de antecedentes (págs. 43/44) observo que a ré não possui maus antecedentes, todavia, analisando os critérios do artigo 42 da Lei de Drogas, que é preponderante sobre o artigo 59 do Código Penal, verifico que a quantidade e natureza das drogas apreendidas, constituem fundamento apto a ensejar o aumento da pena-base, neste sentido, tem decidido o E. Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N.

11.343/2006. PREPONDERÂNCIA. QUANTIDADE INEXPRESSIVA. NATUREZA NOCIVA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL. REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. SÚMULAS 718 E 719 DO STF. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉ PRIMÁRIA E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTIDADE DA DROGA NÃO EXPRESSIVA. MODO ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado. [...] (HC 366112 / SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 28/09/2016; grifei).

Desta forma, majoro a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a provisoriamente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes agravantes e atenuantes, deste modo mantenho a pena provisória em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, vislumbro estar presente a causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, pois a ré é primária e a acusação não conseguiu comprovar que a ré se dedicava a atividade criminosa, nem que integrasse qualquer organização, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa.

Sobre a redução acima aplicada, destaco que nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

"O afastamento da causa de diminuição de pena prevista no §4.º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 exige fundamentação idônea. A ausência de provas do envolvimento em atividades criminosas ou da participação em organização criminosa deve ser interpretada em benefício do acusado e, por conseguinte, não é suficiente para afastar a aplicação da causa de redução da pena. Incidência do princípio da presunção de inocência e da regra do in dubio pro reo" (HC 103225 - RN, 2.ª T., rel. Joaquim Barbosa, 11.10.2011, v.u.).

Segundo o renomado jurista e magistrado GUILHERME DE SOUZA NUCCI, em sua obra "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas - vol.1 -Ed. Forense - 8ª ed. - 2014 - página 348" - a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33 §4º, da Lei 11343/06:

"cuida-se de norma inédita, visando a redução da punição do traficante de primeira viagem, o que merece aplauso. Portanto, aquele que cometer o delito previsto no artigo 33, caput, ou §1º, se primário (indivíduo que não é reincidente, vale dizer, não cometeu outro delito, após ter sido definitivamente condenado anteriormente por crime anterior, no prazo de cinco anos, conforme artigo 63 e 64 do Código Penal) e tiver bons antecedentes (sujeito que não ostenta condenações definitivas anteriores), não se dedicando às atividades criminosas, nem integrando organização criminosa, pode valer-se de pena mais branda.".

Vê-se, portanto, que os quatro requisitos são cumulativos, e devem estar presentes para a concessão da benesse.

Não existem dúvidas quanto aos requisitos da "primariedade", "bons antecedentes" e "integrar organização criminosa", mas estranha é a previsão a respeito de "não se dedicar às atividades criminosas". Segundo o mesmo jurista acima citado, inclusive na mesma obra, "na norma do §4º, para que se possa aplicar a diminuição de pena, afastou-se a possibilidade de ser reincidente ou ter maus antecedentes. Portanto, não se compreende o que significa a previsão de não se dedicar às atividades criminosas. Se o sujeito é reincidente ou tem maus antecedentes pode-se supor que se dedique à atividade criminosa. No mais, sendo primário, com bons antecedentes, não há cabimento em se imaginar a dedicação a tal tipo de atividade ilícita" (grifo nosso).

No caso em tela a ré é primária, impossibilitando, desta forma, a presunção de que se dedique a atividades criminosas. Pelo contrário, é pacífico na doutrina e na jurisprudência que a comprovação dos requisitos "dedicação às atividades criminosas" e "participação em organização criminosa" é ônus da acusação.

Desta forma, sendo a ré primária, e não logrando a acusação comprovar que efetivamente integrasse em organização criminosa, tão pouco se dedicasse a prática de crimes, impossível a não concessão do redutor no caso em tela.

Portanto, será concedido no mínimo legal, pois a quantidade apreendida não pode ser considerada pequena, mas também nada que leve à presunção de que a ré integrava organização criminosa ou se dedicava a atividades criminosas.

Vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por força de expressa proibição legal, e por ser a pena superior a 04 anos. Assim como, em relação à concessão do "sursis" processual.

Dito isso, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime fechado, único adequado e suficiente para reprovar sua conduta que afeta significativamente a ordem social, tendo em vista o incurso no artigo 2º, §1º da Lei nº 8.072/90, com a redação pela lei 11.464/07, os quais justificam a imposição do regime inicial mais severo.

Posto isto:

CONDENO o réu ROBSON VIEIRA MICHELINI qualificado nos autos, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a iniciar o cumprimento no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

CONDENO a ré LUCIANA DE JESUS JACOB qualificada nos autos, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 485 (quatrocentos e oitenta e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal, por infração ao artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal.

Recomende-se o réu Robson na prisão em que se encontra, não podendo recorrer em liberdade, pois ainda presentes os requisitos da custódia cautelar. Em relação a ré Luciana, a ela foi concedida a liberdade provisória, conforme decisão de págs. 152/153, podendo a mesma recorrer em liberdade.

Também, após o trânsito em julgado, oficie-se a Delegacia de Polícia e ao Instituto de Criminalística, autorizando a imediata destruição dos entorpecentes nos termos previstos em lei, remetendo-se auto competente.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do

tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos bens eventualmente apreendidos em poder dos réus em favor da União. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGA (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Oportunamente, intime-se os réus para efetuarem o pagamento da multa.

Condeno-os, ainda, ao pagamento das custas processuais, observando-se eventual condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Arbitro os honorários dos defensores nomeados, se o caso, no valor máximo da tabela vigente, expeça-se o necessário.

P.I.C., arquivando-se, oportunamente.

Itanhaém, 14 de outubro de 2022.

RAFAEL VIEIRA PATARA

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA